

1500535-32.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjisp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500535-32.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2101309/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 24274644 -

DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2101309 - 04º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO PESSOA ALVES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 07 dias do mês de julho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) LUIS FERNANDO PESSOA ALVES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Heverton Alexandre Pezzato Barbosa e André Rodrigues da Silva.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Heverton) pelo sistema virtual

e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha André Rodrigues da Silva.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha André Rodrigues da Silva.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, LUIS FERNANDO PESSOA ALVES está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito processado com regularidade.

Procede a ação penal

DOS FATOS, com indicação de provas da materialidade e autoria

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 12 de abril de 2022, por volta de 17h13min, na Rua Eugênio Quintino, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, LUIS FERNANDO PESSOA ALVES, qualificado e indiciado às fls. 06/07 e 21/22, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 91 (noventa e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 22,2g (vinte e duas gramas e duas decigramas) e 02 (dois) invólucros plásticos contendo Cannabis Sativa L, "maconha", com peso líquido de 2.6g (dois gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta, PAULO – que ostenta envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive no mesmo bairro – trazia consigo porções de maconha e cocaína para comercialização no local, área urbana em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes.1 Em 02 de março de 2016 foi preso em flagrante no mesmo local – Rua Eugênio Quintino, Bairro Algodoal, pelo tráfico de drogas, sendo condenado nos autos n.º 0002870-67.2016.8.26.0451. Estava em plena atividade ilícita quando foi surpreendido pela aproximação de policiais militares motorizados. Diante da iminente abordagem, saiu correndo em direção à comunidade "Vera Cruz". Durante a fuga à pé, PAULO dispensou objetos que trazia consigo. Ao final abordado, foi encontrada em sua posse uma sacola contendo 50 (cinquenta) porções de cocaína e 02 (duas) de maconha, além de R\$43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Em minuciosa busca no trajeto percorrido durante a fuga, os agentes encontraram outros 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles que o denunciado trazia consigo (foto fls. 46/47). Na delegacia, o denunciado negou os fatos (fls. 06/07). Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína e Tetrahidrocannabinol nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 11 e Laudos fls. 13/18e 93/95). Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais, a tentativa de fuga, o local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, a apreensão de maconha e cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, acompanhadas de dinheiro em espécie, é certo que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Heverton Alexandre Pezzato Barbosa – Policial Militar – Estava em patrulhamento ostensivo de rotina quando avistou quatro pessoas conversando numa praça. O policial afirma que se aproximou e resolveu abordar os agentes. Um deles, posteriormente identificado como o indiciado, estava com uma sacola suspeita na mão. Quando desembarcava da viatura, o indiciado correu rumo a comunidade algodoal. Perseguiu-o. Os demais agentes deixaram o local sem serem identificados. Em revista, com o réu localizou a sacola dentro da qual havia cinquenta porções de cocaína e duas porções de maconha. Ademais, havia dinheiro em seu bolso. No caminho da perseguição, seu parceiro de farda recuperou quarenta e uma porções de cocaína. O policial afirma o indiciado, de maneira informal, confessou que estava no local realizando o tráfico de drogas.

No mesmo sentido, André Rodrigues da Silva quando ouvido na fase policial.

Interrogado, o réu negou os fatos. Assumiu a maconha como para uso próprio. Não fugiu. Não estava com a cocaína.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Negativa do réu ilhada. A narrativa dos policiais é consistente e harmoniosa. Merecedora de crédito.

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-

25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito -

Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

Da Dosimetria da Pena

LUIS FERNANDO PESSOA ALVES é portador de maus antecedentes -condenado por tráfico de drogas nos autos n.º 0028015-43.2007.8.26.0451 (fls. 53:pena cumprida em 24/08/2016), por roubo nos autos n.º 0030146-93.2004.8.26.0451 (fls. 53/54:pena cumprida em 24/08/2016), por lesão corporal dolosa nos autos n.º 0002562-31.2016.8.26.0451 (fls. 50: t.j. em 29/10/2018) , por lesão corporal e ameaça nos autos n.º0004485-92.2016.8.26.0451 (fls. 51: t.j. em 01/10/2018) e é reincidente específico -condenado por tráfico de drogas nos autos n.º 0002870-67.2016.8.26.0451 (fls. 51:t.j. em 18/08/2017).

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do

dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

Do pedido final:

Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação penal.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juiza, Luís Fernando Pessoa Alves foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 101-104 e 114-115), no dia 12 de abril de 2022, por volta de 17h13, na rua Eugênio Quintino, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Luís Fernando trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 91 (noventa e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 22,2g (vinte e duas gramas e duas decigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, Luís Fernando trazia consigo porções de cocaína para comercialização no local, área urbana em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Estava em plena atividade ilícita quando foi surpreendido pela aproximação de policiais militares motorizados. Diante da iminente abordagem, saiu correndo em direção à comunidade "Vera Cruz". Durante a fuga a pé, Luís Fernando dispensou objetos que trazia consigo. Ao final abordado, foi encontrada em sua posse uma sacola contendo 50 (cinquenta) porções de cocaína, além de R\$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos). Em minuciosa busca no trajeto percorrido durante a fuga, os agentes encontraram outros 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles que o réu trazia consigo (foto fls. 46-47).

Interrogado em solo policial, o réu disse que: “estava na praça comendo um lanche com sua filha e sua esposa Aline de Moraes numa praça do bairro Algodoal. Não estava com outros três indivíduos, mas somente com a esposa e filha. Correu da abordagem quando viu os militares porque estava portando um cigarro de maconha e estava com mais uma porção de maconha em sua mão. Não portava nenhuma porção de cocaína no momento da abordagem. Não é traficante de drogas e não realizava o tráfico no momento da abordagem. Sua esposa presenciou os fatos, porém não foi conduzida ao distrito policial, sendo que ela queria ter vindo testemunhar” (fls. 6-7).

Heverton Alexandre Pezzato Barbosa, policial militar, narrou que: “estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Eugênio Quintino, quando avistou quatro pessoas conversando numa praça. Aproximou-se e resolveu abordar os agentes em comento para averiguação, porquanto um deles, posteriormente identificado como o indiciado, estava com uma sacola suspeita na mão. Enquanto desembarcava da viatura, o indiciado correu rumo a comunidade algodoal - 'Vera Cruz' - sendo que subiu na motocicleta novamente e o perseguiu. Os demais agentes deixaram o local sem serem identificados. Acompanhou o indiciado em conjunto com seu parceiro de farda, sendo que ele dispensava substâncias suspeitas na fuga. Deteve o implicado no interior da comunidade 'Vera Cruz'. Em revista pessoa, localizou a sacola na posse do indiciado, dentro da qual havia cinquenta porções de cocaína e duas porções de maconha. Ademais, havia dinheiro em seu bolso. Uma vez refazendo o caminho da perseguição, seu parceiro de farda recuperou quarenta e uma porções de cocaína. O indiciado, de maneira informal, confessou que estava no local realizando o tráfico de drogas” (fls. 4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar André Rodrigues da Silva (fls. 5).

Às fls. 11, auto de exibição e apreensão. Às fls. 13-18, laudo de constatação. Às fls. 46 e 47, fotografias. Às fls. 93-95, laudo de exame definitivo.

Às fls. 49-55, juntada certidão de objeto e pé que indica os maus antecedentes (autos n.º 0018583-68.2005.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para o réu em 14/10/2011, pena cumprida ou julgada extinta em 24/8/2016; autos n.º 0028015-43.2007.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para o réu em 6/4/2018, pena cumprida ou julgada extinta em 24/8/2016; autos n.º 0030146-93.2004.8.26.0451 - furto - trânsito em julgado para o réu em 23/7/2007, pena cumprida ou julgada extinta em 24/8/2016) e a reincidência do requerido (autos n.º 0002562-31.2016.8.26.0451 - lesões corporais no âmbito doméstico - trânsito em julgado para a Defesa em 29/10/2018; autos n.º 0002870-67.2016.8.26.0451 - tráfico de drogas - trânsito em julgado para a Defesa em 4/8/2017; autos n.º 0004485-92.2016.8.26.0451 - lesões corporais e ameaça - trânsito em julgado para a Defesa em 1/10/2018).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Com relação à materialidade e autoria, foram colhidos os seguintes elementos em audiência de instrução:

a) Ouvido, inicialmente, Heverton Alexandre Pezzato Barbosa, policial militar. Estava em patrulhamento com motocicleta e saíram próximo à comunidade do Algodoal, saíram em uma praça com 4 pessoas. Iniciaram uma abordagem, os 4 ergueram a mão. De repente, Luís Fernando saiu correndo. Ele ainda não tinha descido da moto. Ele perseguiu o réu de motocicleta. O parceiro tentou alcançar o réu a pé. Durante o trajeto, viu que o réu tinha uma sacola na mão. Coisas iam caindo pelo caminho. Quando o alcançou, encontraram 50 porções de cocaína. O parceiro chegou. Na bermuda tinha duas porções de maconha e algumas moedas, em um dos bolsos. Na cueca, tinha o restante do dinheiro. Quando chegou o apoio de viaturas, refizeram o caminho que Luís percorreu e acharam mais 41 porções de cocaína. Informalmente, o réu confessou a traficância e disse que estava 1 mês na rua - tinha sido preso anteriormente por tráfico no mesmo local. Segundo o réu, voltou a vender drogas por necessidade. Não conhecia o réu. O local em que foi visualizado inicialmente é conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Todas as 91 porções apreendidas eram embaladas de forma idêntica.

b) Por fim, foi interrogado o réu Luís Fernando Pessoa Alves. Negou os fatos. Disse

que mora no bairro, estava na praça e foi abordado. Não fugiu. Apenas tinha maconha, pois é usuário. A cocaína não era sua. Foi levado para a delegacia e somente lá os policiais apresentaram a droga. Não conhecia os policiais de antes da sua prisão anterior. Tinha sido abordado por eles dias antes. Nessa abordagem, eles disseram que, se eles não indicasse uma casa com drogas ou lhes desse um revólver, iam forjá-lo.

- DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

De rigor a improcedência da pretensão acusatória. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento, não foram produzidos elementos de prova que permitam concluir, além de qualquer dúvida razoável, pela responsabilidade penal do réu (CPP, art. 386, V e VII c. c/ art. 155).

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação estaria embasada apenas nas declarações dos policiais, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil. Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para superar o standard probatório da presunção de inocência, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado. De rigor, por isso, que se decrete sua absolvição, na forma do art. 386, VII, do CPP.

- DA DESCLASSIFICAÇÃO: INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

No mais, caso se entenda pela suficiência probatória, impõe-se reconhecer que os elementos de prova produzidos em juízo não são suficientes para a constatação do delito de tráfico de drogas, mas, sim, para a configuração do uso de entorpecentes (LD, art. 28), uma vez que não demonstrado, de maneira inequívoca, o intuito de comercialização da droga e a quantidade de entorpecente apreendida na posse do réu é compatível com o uso de drogas, especialmente porque o réu confirmou que trazia consigo as 2 porções de maconha.

Nessa linha de raciocínio, em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos Autos da Revisão Criminal n. 0025831-60.2017.8.26.0000, valendo-se de pesquisas científicas efetuadas para diferenciar o traficante do usuário, rescindiu condenação proferida pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, entendendo que os fatos estariam melhor enquadrados no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas palavras da Eminente Relatora, "No tocante à quantidade, creio ser importante verificar pesquisas científicas sobre o tema e o 'Estudo Técnico para Sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da lei 11.343/2006', de autoria de Maria Tereza Uille Gomes, de 2014, disponível em www.politicasobredrogas.pr.gov.br, traz valiosas informações de pesquisas científicas realizadas no Brasil. Vejamos: 'Estudo realizado através de pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, constatou que os pacientes viciados em cocaína utilizavam diariamente esta espécie de droga, na forma de sal, em variação de 1 a 10 (um a dez) gramas/dia, com média de 3,8 gramas por dia (ACN Nassif Filho, SG Bettega, S Lunedo, JE Maestri, F Gortz- Repercussões otorrinolaringológicas do abuso de cocaína e/ou crack em dependentes de drogas. Revista das Associação Médica Brasileira, 1999; 45(3): 237-41). Segundo o IC/PR, a médica de uso de cocaína, na forma de crack, é de 15 pedras diárias e de acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Uso de Crack realizada por meio da parceria entre SENAD/MJ e a Fundação Oswaldo

Cruz-FIOCRUZ é de 11 até 16 pedras diárias. A referida pesquisa destaca, no entanto, que não há como definir de forma minimamente precisa o peso em gramas e o conteúdo do que cada usuário denomina 'pedra'. Desse modo, há uma subjetividade intrínseca às definições utilizadas pelos próprios usuários. Inobstante a ressalva feita pela pesquisa, a informação técnica nº 023/2-13 SETEC/SR/DPF/RS

(Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do RGS), constata que cada pedra de crack pode variar de 01 a 1,5 gramas. Segundo o estudo realizado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, a quantidade consumida por usuários de crack variava entre 1 a 15 gramas diárias, sendo que a média identificada foi de uso de 5,2 gramas por dia'. Ainda, no trabalho "Usuário de drogas ilícitas internados em hospitais psiquiátricos: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos", de Paulo Borini e outros, publicado pelo Jornal Brasileiro de Psiquiatria, órgão oficial do IPUB Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do RJ, volume 52, mai/jun 2003, estudo realizado em um hospital psiquiátrico, informa que cerca de 51% são usuários de monodroga e 49% de polidroga. Indica que o consumo diário era igual ou menor de 15 (quinze) gramas de crack, 10 (dez) gramas de maconha e 5 (cinco) gramas de cocaína." (p. 8-9 do Acórdão)".

Outrossim, é necessário atentar-se ao fato de que a discricionariedade policial, consistente no poder de apontar se o indivíduo abordado é usuário ou traficante, deve ser contida em âmbito judicial. Como explica, a propósito, Luís Carlos Valois: "A possibilidade de aquele policial militar decidir, na esquina, se a pessoa abordada é usuária ou traficante de drogas é a mais grave das discricionariedades dessa guerra [guerra às drogas]. Do veredito das ruas poucos podem se livrar e, sacramentado o julgamento, seguirá o indiciado tendo que provar sua inocência com a grande dificuldade de um processo onde todas as testemunhas são policiais" (VALOIS, Luís Carlos. O direito penal da guerra às drogas. 3. ed. Belo Horizonte: D'Plácido, 2019, p. 28).

Por isso, para conter eventuais abusos e evitar injustas condenações, é necessário demonstrar, de maneira inequívoca, que as drogas apreendidas em poder dos acusados se destinavam à comercialização, o que não ocorreu no presente caso. Assim, impõe-se a desclassificação, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça:

"PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo do Ministério Público pela condenação por tráfico, nos termos da denúncia. Inadmissibilidade. Não demonstrado o intuito de entrega do entorpecente a consumo de terceiros. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Desclassificação mantida. Apelo ministerial desprovido. Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o apelo defensivo" (TJ-SP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0001018-89.2017.8.26.0542, Rel. Diniz Fernando, julgado em 16/3/2020).

Com isso, resta configurada a conduta de uso de drogas, e mostra-se imperiosa a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas e exsurtem algumas consequências.

a) Da absolvição por inconstitucionalidade do tipo

A primeira delas é a necessária absolvição em razão da inconstitucionalidade do referido tipo previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, o qual fere o disposto no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Isso porque é inquestionável que a criminalização da posse de drogas para consumo pessoal afeta de modo desproporcional o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, em suas diversas manifestações.

Nas palavras de Salo de Carvalho: "Os direitos à intimidade e à vida privada instrumentalizam em nossa Constituição o postulado da secularização que garante a radical separação entre direito e moral. Neste aspecto, nenhuma norma penal criminalizadora será legítima se intervier nas opções pessoais ou se impuser padrões de comportamento que reforcem concepções morais. A secularização do direito e do processo penal, fruto da recepção constitucional dos valores do pluralismo, da tolerância e do respeito à diversidade, blinda o indivíduo de intervenções indevidas na esfera da interioridade. Assim, está garantida ao sujeito a possibilidade de plena resolução sobre os seus atos (autonomia) [...]" (CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas no Brasil: estudo criminológico e dogmático da Lei 11.343/06. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 343-344).

Adicionalmente, o art. 28 da Lei de Drogas ofende o princípio da lesividade. Ora, um dos preceitos básicos do Direito Penal é a alteridade da lesão, vale dizer, somente se pode criminalizar conduta que ofenda bem jurídico alheio. Como escreve, a propósito, Nilo Batista: "O mesmo fundamento veda a punibilidade da autolesão, ou seja, a conduta externa que, embora vulnerando formalmente um bem jurídico, não ultrapassa o âmbito do próprio autor, como por exemplo o suicídio, a automutilação e o uso de drogas. No Brasil, o art. 28 da Lei n. 11.343, de 23.ago.2006, que incrimina o uso de drogas, em franca oposição ao princípio da lesividade e às mais atuais recomendações político-criminais" (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 90).

Se é assim, tem-se que o consumo de drogas não ofende qualquer bem jurídico alheio, centrando-se na livre determinação do indivíduo que opta por fazer uso do entorpecente.

Desse modo, é inquestionável que qualquer lesão potencial e suposta à saúde pública não pode ser utilizada para legitimar a intervenção penal no indivíduo. A título exemplificativo, o tabaco e o álcool ofereceriam lesividade, mas sua venda e consumo não são criminalizados. Para tais casos, é incontestável que o incremento de medidas restritivas de caráter administrativo, assim como políticas públicas de conscientização sobre o uso abusivo de tais substâncias se mostram eficazes. O mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação às demais drogas.

Anote-se, em reforço, que a criminalização do usuário tem o efeito perverso de rotulá-lo como marginalizado, o que dificulta a sua recuperação, especialmente em se tratando de jovens, que são o principal grupo consumidor de substâncias ilícitas.

Diante da alegação ora invocada, de rigor seja declarada a inconstitucionalidade do tipo penal, em sede de controle difuso, com consequente afastamento da imputação da conduta tipificada pelo art. 28 da Lei de Drogas e absolvição, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

b) Da aplicação de sanção na forma do art. 28 da Lei de Drogas
Rejeitada a pretensão de inconstitucionalidade, mas operada a desclassificação, é o caso de aplicação das sanções cominadas pelo art. 28 da Lei de Drogas.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação, passa-se a discorrer acerca da pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pois não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No mais, as condenações anteriores devem ser avaliadas na segunda fase de fixação de pena, sob pena de bis in idem.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a reincidência deve ser compensada com a confissão, ainda que apenas a informal, sendo ambas as circunstâncias preponderantes (art. 67, do CP).

No mais, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai

do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2). Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

LUIS FERNANDO PESSOA ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de abril de 2022, por volta de 17h13, na Rua Eugênio Quintino, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 91 (noventa e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 22,2g (vinte e duas gramas e duas decigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, LUIS - que ostenta envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive no mesmo bairro - trazia consigo porções de cocaína para comercialização no local, área urbana em que reiteradamente são registradas ocorrências policiais relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Estava em plena atividade ilícita quando foi surpreendido pela aproximação de policiais militares motorizados. Diante da iminente abordagem, saiu correndo em direção à comunidade "Vera Cruz".

Durante a fuga a pé, LUIS dispensou objetos que trazia consigo. Ao final abordado, foi encontrada em sua posse uma sacola contendo 50 (cinquenta) porções de cocaína, além de R\$ 43,65 (quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Em minuciosa busca no trajeto percorrido durante a fuga, os agentes encontraram outros 41 (quarenta e um) eppendorfs de cocaína, idênticos àqueles que o réu trazia consigo (foto fls. 46/47).

Na delegacia, o réu negou os fatos (fls. 06/07).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína na substância apreendida (auto de exibição fls. 11 e Laudos fls. 13/18 e 93/95).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais, a tentativa de fuga, o local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, a apreensão de cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, acompanhadas de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo o entorpecente com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 101), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 105/106).

O Ministério Público aditou a denúncia para constar a quantidade correta de droga apreendida (fls. 114/115) e o aditamento foi recebido (fls. 116).

Notificado (fls. 124), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 130/132).

A denúncia foi recebida, designando-se a audiência (fls.141/143). O réu foi citado (fls. 184).

Durante a instrução, foi ouvida 01 testemunha comum, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 11, no laudo de constatação de fls. 13/18, na fotografia de fls. 46/47, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 93/95, segundo o qual foram detectadas cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC) nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu contou que estava na praça, comendo um lanche com sua filha e sua esposa Aline de Moraes, no Bairro Algodoal. Não estava com outros três indivíduos, mas somente com a esposa e filha. Correu da abordagem quando viu os militares, porque estava portando um cigarro de maconha e estava com mais uma porção de maconha em sua mão. Não portava nenhuma porção de cocaína no momento da abordagem. Não é traficante de drogas e não realizava o tráfico no momento da abordagem. Sua esposa presenciou os fatos, porém, não foi conduzida ao distrito policial, embora ela quisesse testemunhar. Não foi vítima de violência policial (fls. 06/07).

Em Juízo, o réu afirmou que a droga não era sua. A maconha era dele mesmo, mas a cocaína não. Estava na pracinha e não correu para a Comunidade. Foi abordado na pracinha. Viu os policiais e ficou parado. Mora no bairro. Estava apenas com a maconha na mão, porque é usuário e faz uso. Na hora que chegou na Delegacia, os policiais apresentaram a cocaína. Ficou 06 anos na cadeia e estava há poucos dias na rua, nunca iria pegar droga para vender. Na rua, usa maconha e não consegue ficar sem consumi-la. Tinha sido abordado anteriormente, pelos mesmos policiais e disseram eu se não desse uma casa com droga ou uma arma, iria colocar a droga nele. A autoria foi comprovada pelos demais elementos de prova. Vejamos.

O policial militar Heverton Alexandre Pezzato Barbosa afirmou que estavam em patrulhamento de motocicleta e entraram no bairro Algodoal. Cortaram caminho e saíram perto da praça. Visualizaram 04 pessoas, 03 de pé e o réu sentado, e crianças brincando no fundo. Deram voz de abordagem aos 04, desceram da motocicleta e se aproximaram. A princípio, os 04 obedeceram. Quando foi descer da moto, o réu correu para o interior da comunidade e deixou o chinelo. Perseguiu o réu na moto. Seu parceiro soltou a motocicleta e tentou seguir o réu a pé, mas passou por ele e conseguiu deter o réu, com a moto. Percebeu que o réu tinha uma sacola na mão e, durante a fuga, alguma coisa ia caindo. Conseguiu abordar o réu. Na sacola, havia 50 pinos de cocaína. Na bermuda do réu havia 02 invólucros de maconha e um pouco de moedas. Na cintura do réu, dentro da cueca, havia dinheiro. Refizeram o caminho e conseguiram encontrar mais 41 pinos de cocaína. O réu acabou dizendo que estava há poucos dias na rua e, por causa da necessidade, por não conseguir trabalho, estava vendendo drogas. Não conhecia o réu. A praça é conhecida por ser ponto de venda de drogas. Os pinos de cocaína eram todos idênticos.

Ouvido apenas na Delegacia de Polícia, o policial militar André Rodrigues da Silva comentou que estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela Rua Eugênio Quintino, quando avistou quatro pessoas conversando numa praça e seu parceiro de farda resolveu abordá-las em decorrência de uma delas estar com uma sacola suspeita numa das mãos. Quando desembarcava da moto, o réu correu rumo à Comunidade Algodoal - "Vera Cruz". Subiu novamente na motocicleta e o perseguiu. Os demais agentes deixaram o local sem serem identificados. Acompanhou o réu em conjunto com seu parceiro de farda e, durante a fuga, o réu dispensava substâncias suspeitas. Detiveram o réu no interior da comunidade "Vera Cruz". Em revista pessoa, seu parceiro de farda localizou a sacola na posse do réu, dentro da qual havia 50 porções de cocaína e 02 porções de maconha. Uma vez refazendo o caminho da perseguição, recuperou 41 porções de cocaína. O réu, de maneira informal, confessou que estava no local realizando o tráfico de drogas (fls.05).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, afirmou que tinha em sua posse apenas um cigarro de maconha e uma porção da mesma droga. Judicialmente, o réu alegou que só tinha consigo 02 porções de maconha, para o uso próprio.

Os policiais militares descreveram que avistaram o réu e mais 03 pessoas em uma

praça e resolveram abordá-los. Quando desembarcavam das motocicletas, o réu empreendeu fuga a pé, entrando na comunidade. Os policiais iniciaram perseguição com a motocicleta, mas o policial André acabou descendo da moto, para tentar a abordagem. O policial Heverton seguiu com a motocicleta e conseguiu a abordagem. Durante a fuga, o policial Heverton presenciou o réu dispensando alguma coisa da sacola que trazia consigo. O réu foi detido e, em revista pessoal, os policiais encontraram a sacola, dentro da qual havia 50 porções de cocaína. No bolso da bermuda do réu havia 02 porções de maconha e moedas. Na cueca do réu havia mais dinheiro. Ao refazer o caminho da fuga, os policiais localizaram mais 41 porções de cocaína. Informalmente, o réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas. Com efeito, temos duas versões sobre o mesmo fato: a do réu, que confirma apenas a posse de duas porções de maconha, e a dos policiais, no sentido de que parte da droga foi apreendida em poder do réu (50 porções de cocaína e 02 porções de maconha) e o restante foi por ele dispensado, durante a fuga (41 porções de cocaína).

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Numa primeira análise, o réu, quando avistou a aproximação dos policiais, que desembarcaram da motocicleta, empreendeu fuga, o que já demonstra sua atividade ilícita.

De mais a mais, a apreensão da droga confirma a versão dos policiais que, segura e uníssona, prevalecem sobre a negativa de autoria por parte do réu.

Importante mencionar que o réu alegou que a esposa teria presenciado os fatos, mas não a arrolou para ser ouvida nos autos.

Por fim, como já vem decidindo a jurisprudência, a palavra de policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, em especial quando acompanhada do restante da prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

(...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou

orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Comprovado que a droga estava em poder do réu, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência de dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

O réu afirmou que só tinha duas porções de maconha, para seu próprio consumo.

Outras provas, contudo, indicam a destinação de tráfico de drogas. Vejamos.

Inicialmente, os policiais militares resolveram abordar 04 rapazes que conversavam numa praça, no entanto, quando percebeu que os policiais estavam desembarcando das motocicletas, o réu empreendeu fuga, revelando conduta ilícita.

Na fuga, o réu foi dispensando drogas que, depois que ele foi detido, foram apreendidas.

A quantidade e diversidade da droga apreendida (91 porções de cocaína e 02 porções de maconha) indicam que a droga não seria para consumo próprio, porque usuários não mantêm essa quantidade de droga em seu poder.

Além disso, no bolso do réu havia R\$ 43,56 em notas trocadas, cuja procedência lícita não foi comprovada (vide fotografia de fls. 46).

Por fim, informalmente, aos policiais militares, o réu confessou que estava praticando o comércio espúrio de drogas.

Assim, a fuga do réu, a quantidade, diversidade e forma de embalo do entorpecentes, a confissão informal, tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação a mercancia ilícita.

Ressalto que, ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno -

Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal -Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de